

1500081-37.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas, e para que seja desclassificada conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ou pela aplicação da figura do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu primário, bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa e não integra qualquer organização ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500081-37.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500081-37.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL LUCAS MATU VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra GABRIEL LUCAS MATU VIEIRA, qualificado à fl. 05, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18 de janeiro de 2021, por volta de 06h00, na Rua Coronel Albino, nº 190, Vila Maristela, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o DENUNCIADO guardava e tinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em forma de tijolo, com peso líquido de 284,23g (duzentos e oitenta e quatro gramas mais vinte e três centigramas), bem como 06 (seis) porções de maconha, envoltas por por plástico do tipo "filme", com peso líquido de 101,31g (cento e um gramas mais trinta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo pericial de fls. 131/135, atestando a potencialidade das drogas. Narram os autos que o DENUNCIADO adquiriu o referido entorpecente em lugar e de pessoas até o momento não identificadas e as guardou na

sua residência, no endereço acima mencionado, para posteriormente comercializá-la. Contudo, no dia dos fatos, Policiais Civis em cumprimento dos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Presidente Prudente, nos autos nº 1500138-67.2021.8.26.0482, em desfavor do DENUNCIADO, se dirigiram à residência dele situada no endereço acima. Chegando ao local, após apresentado e lido os mandados, os policiais lograram êxito em encontrar dentro do guarda-roupas uma porção de maconha em forma de tijolo, bem como outras 06 (seis) porções contendo maconha, envoltas em plástico do tipo "filme", prontas à venda, além de objetos relacionados ao tráfico de drogas como 01 (uma) faca e frascos de lança perfume localizados na cômoda do quarto, 02 (dois) aparelhos de telefone celular e a quantia de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) em dinheiro. Questionado, o DENUNCIADO confirmou que a droga era para a revenda e consumo próprio, porém se reservou ao direito constitucional ao silêncio quanto aos fornecedores dos entorpecentes apreendidos. O laudo pericial de fls. 131/135 evidencia a presença de tetrahidrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas. As circunstâncias em que se deram os fatos, somadas à quantidade de drogas apreendidas, a forma como as porções estavam divididas e armazenadas, além da significativa quantia em dinheiro encontrada no local, sem indícios da licitude da sua origem, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga seria destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 159/164), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 168), o despacho de fls. 169/173, de 15 de março de 2021, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 313/318), pediu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu, nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 321/326), requer a absolvição do réu, por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas, e para que seja desclassificada conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ou pela aplicação da figura do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu primário, bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa e não integra qualquer organização criminosa.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls.

11/12; pelo relatório de investigação policial de fls. 22/35; pelo laudo de constatação preliminar de fls. 14/16; pelo laudo químico toxicológico de fls.

133/135, atestando - Item 1 (Acondicionado sob o lacre 0026348 (D8DSPP)) Descrição: 1 (um) invólucro(s) constituído(s) por fita(s) adesiva(s) e plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, compactados na forma de tijolo. Massa Bruta e/ou Quantidade: 301,12 grama(s) - trezentos e um gramas e doze centigramas. Massa Líquida: 284,23 grama(s) - duzentos e oitenta e quatro gramas e vinte e três centigramas. Item 2 (Acondicionado sob o lacre 0026347 (D8DSPP)) Descrição: 6 (seis) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido, todos encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 115,75 grama(s) - cento e quinze gramas e setenta e cinco centigramas. Massa Líquida: 101,31 grama(s) - cento e um gramas e trinta e um centigramas. Resultado: A análise do material

descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial de objetos de fls. 146/148 que analisou Item A (Acondicionado sob o lacre 11094 ) Descrição: 01 (um) pote de vidro de formato cilíndrico, usado e em bom estado de conservação, com tampa de rosca de material sintético de cor preta contendo inscrição "Invicta", e Item B (Acondicionado sob o lacre 11095 ) Descrição: 01 (uma) faca, usada e em regular estado de conservação, constituída por lâmina metálica de gume serrilhado contendo inscrições "AÇONOBRE", "INOX", "BRASIL"; e por um cabo de material sintético. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 68/131; comprovante de depósito do dinheiro apreendido de fl. 136; além da prova oral carreada para os autos.

Foi instaurado incidente de verificação de dependência toxicológica (apenso) em que os experts discutiram e constataram que o réu "é usuário eventual de maconha e não apresenta Transtorno ou Doença mental decorrente do uso de drogas. Tinha á época dos fatos plena capacidade de entendimento e determinação quanto a ação que lhe é imputada", concluindo assim que "- Não é dependente químico. - Não há doença ou Transtorno mental. - É pessoa plenamente capaz de entender e de se determinar. - Não havia prejuízo de entendimento ou determinação pelo uso de drogas."

Em Juízo, o Policial Civil Willian Gomes Namura, sob o crivo do contraditório declarou que os fatos ocorreram pela deflagração da "operação Taric II", e de posse do mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária expedidos contra o acusado, e quando chegaram até a residência dele, quando ele percebeu a presença da equipe, tentou fugir dentro da residência, foi contido e se acalmou, disse-nos que achou ser o padrasto que estava lá. Informamos o motivo de estarmos lá, relacionado ao tráfico de drogas e nos disse que não havia droga em sua casa, mas em buscas no imóvel, lograram encontrar as porções de drogas, meio tijolo de maconha em forma bruta, e porções embalada prontas para venda, dentro de um pote e várias embalagens para embalar a droga, frasco de lança perfume e bicos de frasco de lança perfume, bem como dinheiro e tudo apresentado na Delegacia. Gabriel, a princípio negou tudo, após encontrar as drogas ele assumiu e confessou que realmente vendia drogas. Quando chegou nesta especializada auxiliou a finalizar o relatório com base em laudos de celular apreendidos durante a primeira fase da operação, onde o nome dele foi citado, envolvido no comércio de drogas. Não foi encontrada nenhuma arma de fogo. A residência fica num bairro de alto padrão, mas ao chegar no quarto dele já puderam sentir o odor de entorpecentes.

A testemunha Policial Civil Luiz Henrique Pancotti, sob o crivo do contraditório declarou que participou da ocorrência e lá chegando, o acusado já saiu correndo para os fundos da residência, para os quartos. Contido, foi indagado se havia entorpecentes na residência, ele negou, mas em buscas no local foi encontrada as primeiras porções dentro do guarda-roupas, e novamente foi indagado se havia mais alguma coisa, e novamente ele negou, mas acabaram encontrando mais drogas escondidas, frascos de lança perfume no quarto dele. Sobre o encontro das drogas não ouviu a sua justificativa, pois tentava acalmar a avó dele que estava bastante nervosa. Sobre o dinheiro, encontraram dentro do guarda-roupa. A casa tinha aspecto de ser bem arrumada, morava com a avó e a irmã, em quartos separados, e no do réu que foi encontrada a droga. Os frascos de lança perfume estavam vazios.

A testemunha Eliezer Harthopf, declarou que conhece o réu pois ele instalava ar condicionado e instalou em sua casa e lhe dava manutenção. Pelo que conhece, há mais de dois anos, sempre viu ele trabalhando, sabe que ele é usuário, porque ouviu todo mundo falando, mas nunca soube que fazia o tráfico. Sabe que ele usava maconha, não soube que ele era traficante, e acha que ele trabalha somente com ar condicionado.

A testemunha João Batista Galindo de Oliveira, sob o crivo do contraditório, afirmou que o acusado presta serviço em sua residência, instalação e manutenção de ar condicionado. Sabe que ele é eletricista, parte elétrica. Sabe que ele é

usuário, de maconha, já presenciou. Disse que é trabalhador e honesto.

O réu Gabriel Lucas Matu Vieira, em seu interrogatório declarou que nunca foi preso ou cumpriu pena anteriormente. Sobre os fatos disse que a droga era sua por ser usuário, e ainda é. Afirmo que pegava a droga e vendia e fumava um pouco, mas nunca pegou dinheiro em mãos, sempre pegava em droga, para suprir seu vício. Quando chegou a pandemia, perdeu o emprego e começou a consertar ar condicionado, e sempre sozinho, mas sempre trabalhou como eletricitista. Quanto aos frascos de lança perfume, comprou numa festa e guardou em sua residência, mas nunca fez uso deles. Afirmo que vendia droga sim, mas não pegava dinheiro, apenas mais droga. Vendia droga para essa pessoa e depois ela lhe pagava com mais droga para seu uso. Pegava a droga de uma pessoa, vendia, mas não pegava dinheiro, pegava em droga para passar para os outros. O terceiro para quem vendia, pagava em dinheiro, mas passava sempre para a pessoa que pegava, era um tipo de comissão em droga. Já vinha fazendo isso desde que saiu do serviço, há uns quatro meses, e o dinheiro é fruto do seu trabalho, para pagar o documento da sua moto que estava atrasado, sua avó que emprestou e iria paga-la depois.

Encerrando-se a instrução processual.

Desse modo, entendo que o valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa. (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (1 tijolo de maconha pesando 301 gramas e vários papérols já confeccionados para a venda pesando 116 gramas), bem como numerário (R\$ 580,00), sem qualquer comprovação da origem lícita, uma faca com resquícios de droga, além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Também não prospera a alegação de que a droga era para consumo próprio, já que também foi desmentida pela prova dos autos, por ele mesmo que admitiu comprar drogas do fornecedor, vender para usuários, mas não ficava com o dinheiro arrecadado, apenas repassava para o seu fornecedor que também, de certa forma, lhe pagava com droga.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, a apreensão do dinheiro R\$ 580,00, egundo a apreensão era bastante notas de R\$ 2,00, de R\$ 5,00, de R\$ 10 que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada aos demais objetos e a droga, uma pedra bruta que pesou cerca de 311 gramas de maconha, que renderia muitas porções após fracionadas para a venda, além das porções já embaladas para a venda, a faca com resquícios da mesma droga, frascos de lança perfume, embora vazios.

Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu. Outrossim, a droga apreendida, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, a operação Taric II, já vinha se desenrolando há tempo, com investigação de inteligência e de campo, entretanto, o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi suficiente para a comprovação das suspeitas, e por fim, o réu nada trouxe aos autos que pudesse comprovar a origem lícita do numerário apreendido em sua posse, disse que foi sua avó que lhe emprestou para regularizar o documento de sua moto que estava em atraso, todavia, não trouxe qualquer documento ou testemunha para corroborar com a

sua narrativa, o que faz crer que era fruto da traficância de drogas por ele exercida.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Pelos detalhes acima extraídos da prova dos autos, não se pode acolher a negativa do réu e nem o pedido de desclassificação para o delito posse para consumo pessoal, já que é evidente a sua condição de traficante, confessado em Juízo na presença de seu advogado constituído.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos."

(Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745);

"Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

A isso tudo se alia o constatado pela perícia nos dois celulares apreendidos de propriedade de Gabriel Lucas (fls. 68/118), consta conta de e-mail vinculada - gabriellucasgbl@icloud.com e gabrielamatu8@gmail.com, Número vinculado ao WhatsApp: +551899639135 e +5518991971219, onde há inúmeras conversas direcionada ao tráfico de drogas, que denotam a compra de muito entorpecentes, vários tipos de drogas,

maconha, raxixe, lança perfume, intensa negociação entre o réu e uma pessoa de nome Matheus Santos com alto valores em dinheiro, que comprovam a grande quantidade de droga adquirida pelo acusado, chamando a atenção os diálogos de folhas 75

“+5518996369135@s.whatsapp.net Gabriel Mattu Saída (mensagem de áudio: Pra mim, da sim, da sim, da sim, ficou um pouquinho as caro, mas ta ligado. Mas deixa eu fala pro cê, será que tem como nós faze assim ôh, se liga, é... eu te manda os quatrocentos e cinquenta, e fica te devendo uns três mil pra essa semana. Quando chega eu já faço um giro e te mando, ta ligado que o bagueio é responsa.)” e em resposta, “5518981952303@s.what sapp.net Matheus Santos Entrada (mensagem de áudio: Como eu já pedi o mano ali, ele pergunto, achei que tinha sido a vista, eu falei pra ele que tinha sido a vista, dessa vez vai ter que ser a vista, viado, mas dai dá próxima, pode pah mano, fecho, aí nós faz igual a ultima vez). Olá! Estes são os dados da minha conta C6: Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001 Conta Corrente: 2713130-0 CPF: 433.464.118-00 Nome: tayna Nunes Oliveira. (mensagem de áudio: Cê mandando o comprovante, o pedido já sai hoje, ta ligado?). (mensagem de áudio: Porque quando é frete, nós já manda pro parceiro lá de São Paulo, ele já manda pra nós ta ligado? Nós nem tem que ir no correio manda. pra voces, por isso que pedi um poquinho mais caro, que ele cobra, ta ligado. Esses corre xxxx nós pega com ele, que ele é parceiro nosso, quando ele tem que solta aqui na Baixada, nós solta pra ele e quando nós tem que solta pra corre, ele solta pra nós em São Paulo). (mensagem de áudio: Nossa Mané fala pro cê que tipo assim, fala pro cê que pra mim paga assim a vista no dinheiro, agora vai se ruim pra mim Cusão, porque eu fiz uma tacada nos mato, ta ligado? Peguei pouquinho peça mas o dinheiro que eu tinha investido, ta ligado, fico que meio na maconha, ta ligado cusão? Fala pro Cê que acho que a vista pra mim manda já hoje pro cê eu não vo te Cusão. Na onde eu falei que meu pensamento era pega essas caminhada porque eu giro rápido, ta ligado e já te mandava na sequencia Cusão.)”.

Em outro diálogo que também envolve negociação de drogas, Gabriel agora trata com Ricardo Arthur (fl. 78) - “100002116499086 Ricardo Arthur Entrada “licença aqui na humildade manin , e esse cha vem qnts G ?? como eu chego nele kkk fiquei interessado tlg veinho , moro interior de sp mo corre pra pega um verde”, que tal pessoa mora na cidade de São Roque, além de tantas outras, com várias pessoas diferentes, há também inúmeras fotos de grande quantidade de droga, maconha, raxixe, ecstase, cocaína, amostras dos tipos de drogas que se vende (fl. 102), grande quantidade de dinheiro, armas de fogo, drogas sendo pesadas em balanças de precisão, comumente utilizadas pelos traficantes, pessoas fazendo uso de drogas, comprovante de depósitos, fotos inclusive de frascos de lança perfume, que certamente são vendidos pelo réu, há também alguns prints de festas Rave onde são comercializadas abertamente grande quantidade de drogas, sempre as escondidas, e nesses locais são vendidas a grande variedade de drogas, como demonstra os prints desses grupos formados para um tipo de venda antecipada ou de pessoas interessadas em adquirir as drogas, como se fosse um mercado, onde se oferece todo tipo de drogas, conforme se observa as folhas 107/110 e 113/115.

Observo que ambos celulares pertencem ao réu Gabriel, e possui fotos que foram tiradas do próprio celular do réu, traziam em seu metadados, informações do aparelho que produziu a foto e a geolocalização de onde foi tirada a foto, onde o réu aparece com grande quantidade de dinheiro, incompatível com seu meio de vida, situação típica de quem se exhibi com o lucro fácil do comércio de drogas, e portanto, evidencia com grande eloquencia nos autos a participação direta do réu no comércio espúrio de drogas.

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava na residência, de onde retirava parte para a venda a terceiro, enquanto a maior parte ficava escondida na residência onde mora com a avó e a irmã, segundo ele.

Nem mesmo as testemunhas que tentaram dar um ar de veracidade na versão de que é somente um usuário, posto que as versões delas não se harmonizam com as demais provas carreadas aos autos. Ou seja, são tão contraditórios os relatos, que não merecem nenhuma credibilidade, aliás, confirmam que o réu é notório usuário de drogas, fato que é comum entre os traficantes também.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, impossível acolher o pedido da Defesa do réu para desclassificação do delito de tráfico para o de porte de droga para consumo pessoal, já que, ao contrário do que alega a defesa, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas na residência, sendo certo que o traficante, muitas vezes, também é usuário de droga, sem perder a qualidade primária, procedendo a ação penal como pedido na denúncia. Neste sentido:

"Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga e a forma de acondicionamento demonstram a traficância. Impossibilidade de desclassificação para o uso. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Condenação bem proferida. Possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (Ap. Criminal nº 990.10.183740-4 – Registro – 9ª Câmara de Direito Criminal – Relator Desembargador Francisco Bruno).

A propósito:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

"Tóxico Tráfico Desclassificação - Inadmissibilidade - Ausência de prova de que a droga apreendida destinava-se ao uso exclusivo do réu - Ônus da prova a cargo da defesa - Condenação mantida para o crime de tráfico que restou indubitavelmente comprovado nos autos." (Apelação Criminal n.º 270.095-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 24.06.99 - V.U.).

Destarte, as provas produzidas permitem a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de manter em depósito e venda de droga e, com isto, auferir lucro fácil, não podendo ser acatadas as teses da Defesa de insuficiência probatória, negativa de autoria e desclassificatória para o artigo 28, da Lei em comento.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu por tráfico de drogas.

Passo a dosagem da pena.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem bis.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminoso. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem.

Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONDEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem.[...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser

consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]" (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]" (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]". (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59, lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea do réu em Juízo, conforme preceitua o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, entretanto, deixo de reduzir a reprimenda, porquanto nessa fase do cálculo penal não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ), nesse particularizado caso, o réu admitiu a propriedade das drogas e praticava a venda de drogas, comprovando o tráfico de drogas, de acordo com a Súmula 630 do STJ: "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

As quantidades de drogas e de dinheiro apreendidos em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga e o pouco de dinheiro apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art.

5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplica do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital de Esperança (do Câncer) de Presidente Prudente.

Em caso de revogação das penas restritivas de direitos, o réu cumprirá a pena corporal fixada nesta sentença no regime aberto.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu GABRIEL LUCAS MATU VIEIRA, RG: 55174396, nascido em 13/05/1996, natural de Presidente Prudente - SP, filho de LUCIANO LUCAS VIEIRA e ELIANA APARECIDA MATU, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital de Esperança de Presidente Prudente(Hospital do Câncer); e a pagar a multa de valor correspondente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cada dia no valor mínimo legal, por violação do artigo 33, "caput", c/c o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Quando da execução a multa deverá ser corrigida monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Decreto a perda em favor da UNIÃO de todo o numerário apreendido nos autos, posto que oriundo do tráfico de drogas.

Determino a imediata destruição dos aparelhos celulares apreendidos nos autos posto que utilizados para o tráfico conforme demonstrou a perícia neles realizada.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA